

Aspectos Legales y Profesionales

Estructura Constitucional

A.- Constitución formal y material:

Cuando en derecho hablamos de estructura constitución en realidad estamos mencionando dos conceptos que, si bien revisten puntos en común, no son idénticos.

La primera aproximación al término constitución nos remite a la existencia de un texto legal sancionado por un órgano particular, la convención constituyente. Este texto mantiene un carácter supra legal, de forma tal que todo el contenido del ordenamiento jurídico se puede derivar del mismo. Las características de la constitución escrita serían las siguientes

- La constitución es una ley
- Esa ley es escrita
- Se encuentra reunida íntegramente en texto único y sistematizado
- Este texto es sancionado por la convención constituyente y no por el poder legislativo.
- Constituye la norma fundamental del ordenamiento jurídico

Sin embargo, si queremos realmente entender cómo funciona el esquema de poder de un estado, no podemos simplemente quedarnos en el análisis del simple texto, siendo necesario estudiar su real aplicación. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que ciertos estados carecen de constitución escrita, debiendo analizarse los comportamientos sociales como forma de determinar la estructura del estado. Estamos en tal caso ante una constitución en sentido material.

Todos los estados tienen una constitución material, ya que esta constituido o funciona de una manera determinada, aun en los casos en que no exista un texto escrito. Aun en el caso de que exista una constitución escrita, debe tenerse en cuenta que la constitución material excede el contenido de la primera. Esto es así porque aún en el caso de la plena aplicación del contenido

escrito, existen elementos que se incorporan fuera y al margen de la constitución formal, como por ejemplo la jurisprudencia de los tribunales respecto de las cláusulas.

El contenido de la constitución tanto formal como material esta dado por dos grandes campos: el que se refiere al ejercicio del poder, en lo referente a la conformación de los órganos de gobierno, su funcionamiento y capacidades y, en segundo lugar, la posición de los sujetos frente la estado. La primera es la conocida como parte orgánica de la constitución, mientras que la segunda recibe el nombre de parte dogmática.

Puede que la constitución formal y la material coincida, de forma tal que todo el texto constitucional tiene vigencia y aplicación. Sin embargo puede suceder que la constitución material presente discrepancias con la formal. Ello puede suceder porque ciertas cláusulas contenidas en el texto cayeron en desuso, como puede ser la potestad del estado nacional de otorgar patentes de corso (autorización para el ejercicio de la piratería). También puede suceder que la cláusula nunca haya llegado a implementarse, como el caso de la regulación del juicio por jurados.

II.- Principio de supremacía constitucional

Art. 31.- *Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.*

Hans Kelsen, un catedrático y teórico del derecho vienes, entendía al ordenamiento jurídico como una estructura piramidal en la que la constitución constituye el vértice superior y el fundamento lógico de las restantes normas. Esta visión se encuentra en concordancia con

el artículo transcrito anteriormente, de forma tal que la constitución establece los límites de la normativa que encuentra en ella su justificación.

La supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto debe ajustarse al contenido de la constitución.

Cuando una norma inferior contradice al texto constitucional se produce un fenómeno jurídico conocido como inconstitucionalidad. Tales actos se encuentran privados de validez por el ordenamiento jurídico y se reputan nulos, de forma tal de evitar contradecir la estructura lógica que reseñábamos en los párrafos anteriores.

Como consecuencia directa de ello, se hace necesario un mecanismo que permita detectar y declarar las normas inconstitucionales. Tales soluciones se engloban la denominación de *sistemas de control o revisión constitucional*.

Respecto al alcance del control constitucional, por principio, todos los actos y normas, ya sea de particulares o del propio estado, se encuentran sujetos al control constitucional. Sin embargo, cierta doctrina y jurisprudencia admite la existencia de una excepción en los casos de las llamadas “*cuestiones políticas no judiciales*”, las que quedarían fuera del control. Ello no quiere decir que respecto a estas la supremacía constitucional no exista sino que la misma no puede ser ejercida mediante una acción ante el organismo de control.

Algunos autores critican esta concepción por entender que la misma modifica la constitución escrita, introduciendo por vía interpretativa excepciones no contenida en el texto. En realidad que los casos en que se plantea la existencia de cuestiones políticas (Ej. declaraciones de guerra o de estado de sitio) no se esta frente una excepción sino a un limitación propia del mecanismo de control. El organismo de contralor no analiza la oportunidad de la medida sino solamente sino la concordancia con el texto constitucional. Si analizamos por ejemplo la declaración de guerra, existe un control constitucional en referencia al órgano competente para realizarla pero respecto a las razones para la misma toda vez que la constitución nada dice al respecto. Por lo tanto no es que la cuestión este exenta del control

constitucional sino que este no puede avanzar sobre cuestiones que exceden al marco de dicha norma.

Respecto de los mecanismos de control constitucional, los mismos pueden clasificarse según sus características fundamentales de la siguiente manera:

1.- Por el órgano que toma a cargo su control: El mecanismo puede ser político, si es que el órgano encargado permanece en la órbita del poder político. Tal es el caso del Tribunal de Control Constitucional de Francia creado en el año 1958.

Puede asimismo ser jurisdiccional cuando queda en la órbita de la administración de justicia. En tal sentido debe diferenciarse los casos en que la posibilidad de controlar se encuentra otorgadas todos los jueces sin diferenciación del fuero, en cuyo caso el sistema se conoce como difuso, o cuando existe un único organismo encargado de la declaración de inconstitucionalidad, en cuyo caso nos encontramos frente a un sistema concentrado.

2.- Por las vías procesales mediante puede introducirse la cuestión constitucional el sistema puede ser directo en los casos en la demanda tiene por objeto la declaración de inconstitucional de una norma u acto.

Asimismo, puede ser que la cuestión constitucional no sea el objeto principal de la acción sino que constituye una cuestión incidental dentro de una pretensión diferente, con la que mantiene una relación instrumental. Por ejemplo, si se busca la declaración de inconstitucionalidad de una ley que impide expulsión de los deudores morosos dentro de un juicio de desalojo, lo que se busca no es la declaración en sí sino la posibilidad de seguir con el juicio a los efectos de recuperar el inmueble, constituyendo la declaración de inconstitucionalidad un medio y no un fin en sí mismo. En tal caso estaremos frente a un control constitucional indirecto.

3.- Por último, y respecto a los efectos que la declaración pueda tener la misma pueden limitarse al caso bajo estudio (efectos limitados o inter-partes) o extenderse a los casos hipotéticamente comprendidos en la norma (efectos amplios o *erga omnes*). En este último caso, el órgano de contralor puede directamente decretar la nulidad de la

norma o simplemente ordenarle al órgano encargado de su sanción que la derogue.

En el gobierno federal argentino y atento que la constitución prohíbe al poder ejecutivo conocer en causas judiciales, el control constitucional es exclusivamente judicial. Asimismo, este control es potestad de todos los jueces del fuero, los que se expiden por vía incidental con efectos limitados a las partes.

En las constituciones provinciales la cuestión varía, ya que muchos ordenamientos (entre otras la provincia de Buenos Aires) prevén una acción de declaración de inconstitucionalidad directa. En tales casos, la mayoría de las legislaciones reservan el trámite de la pretensión al superior tribunal local (en el caso bonaerense la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires), constituyendo un caso de control constitucional concentrado.

Respecto de los efectos, la mayoría de las legislaciones le otorgan efectos entre partes. Sin embargo, en las constituciones provinciales más modernas se admite los efectos generales. Así, por ejemplo, la constitución de la provincia de Río Negro estipula que al tercer pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad de una norma, el tribunal puede declarar suspendida la aplicación de la norma. Similares sistemas presentan las constituciones de Santiago del Estero y Neuquén, entre otras.

III.- Las Garantías Constitucionales

Art. 43.- *Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.*

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a l

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el

afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

Las garantías constitucionales son mecanismos de protección jurídica de los particulares frente a estado, a los efectos de que este asegure la vigencia de los derechos consagrados a los ciudadanos.

En un sentido amplio todo el ordenamiento jurídico constituye una garantía del individuo. Sin embargo, en un más específicamente, encontraremos garantías constitucionales en los casos en que el particular puede movilizar la estructura del estado para defender sus derechos.

En el sentido más estricto encontraremos garantías constitucionales en los casos de los procesos judiciales comprendidos en el art. 43 de nuestra constitución nacional: El habeas corpus, amparo y habeas data.

Debe tenerse en cuenta que en todos los casos si bien constituyen acciones de índole constitucional, su regulación procesal queda supeditada a la reglamentación que las provincias decidan darle en sus códigos forma.

El *habeas corpus* es una garantía tradicional que tutela la libertad física o ambulatoria de una persona contra acciones que de cualquier forma la restrinjan en forma arbitraria o sin formas legales. Así, las detenciones, demoras, prohibiciones de circular o arrestos son acciones, que cuando carecen de marco legal que las fundamente, dan pie a la acción.

La misma procede a pedido de un particular o de oficio por el propio juez en los casos en forma arbitraria se restrinja la libertad o de modifiquen las condiciones de detención de una persona. El procedimiento es abreviado pero garantiza la audiencia tanto del damnificado como del organismo denunciado. Esto se hace mediante el llamado auto de habeas corpus, orden judicial en la que se intima al organismo denunciado a informar si la persona se encuentra retenida, las causas de su detención y, en su caso, puede llegar a ordenar la presentación de la misma en sede judicial.

El amparo se asemeja al habeas corpus en cuanto ambos constituyen una vía procesal sumaria a los efectos de asegurar los derechos de los particulares. Sin embargo mientras el habeas corpus protege la libertad ambulatoria, el amparo es una garantía de carácter subsidiario resguardando el conjunto de derechos consagrados por la constitución que carecen de una vía procesal específica.

Otra diferencia es que a diferencia del habeas corpus¹, el amparo no tuvo recepción constitucional hasta el año 1994, siendo básicamente una creación jurisprudencial. Hasta 1957 los tribunales argentinos negaban la procedencia de la figura, basándose en la inexistencia de una regulación específica. Este criterio se modificó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como caso *Siri*, en el que el máximo tribunal admitió la existencia de una acción similar al habeas corpus para salvaguardar derechos no protegidos por el habeas corpus (en este caso la libertad de expresión). En el siguiente año, el tribunal extendió la procedencia de la garantía para los casos de actos realizados por particulares en el caso *Kot*.

En 1966 comenzó con la sanción en el ámbito federal de la ley 16.986 de amparo contra los actos del estado un proceso de reglamentación de la figura que limitó en forma sustancial la utilidad de la misma. En particular impusieron las siguientes condiciones para su procedencia:

1.- El agravio del derecho debe derivar de un acto que sea manifiestamente ilegal o arbitrario: Por lo tanto el amparo no procede en los casos en que el acto atacado se basa en el cumplimiento de normas de carácter general como asimismo cuando el derecho a proteger aparece como dudoso o discutible. Asimismo, la legislación había limitado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas aunque dicha restricción fue levantada al consagrar el instituto a nivel constitucional en el año 1994.

2.- El amparo no procede en los casos en que exista otras vías o recursos administrativos o judiciales para impugnar el

¹ Si bien no se consagraba expresamente el habeas corpus encontraba su fundamento en el art. 18 de la constitución nacional.

acto. Esto significaba que antes de iniciar el amparo era menester haber agotado todos los recursos y vías previas y que asimismo tampoco pueda remitirse a los procedimientos ordinarios. En este condicionamiento fue modificado sustancialmente por el art. 43 de la Constitución Nacional al sostener que el mismo es procedente en el caso que no exista una vía judicial más idónea. Ello implica que ya no es necesario agotar la vía administrativa para la procedencia del instituto, así como que las vías judiciales que permiten el rechazo deben ser igualmente idóneas para lograr la protección buscada.

Por último, el Habeas Data como garantía tiene su origen en la reforma constitucional de 1994. , constituyendo una figura específica del amparo, destinada a proteger los datos personales.

Atento su importancia, diferiremos su tratamiento hasta el análisis de la ley de bancos de datos.

B.- Forma del Estado y del Gobierno:

<i>Art. 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.</i>
--

El art. 1 de la constitución nacional ha permanecido inalterado desde su formulación en el año 1853. Tal como surge de su texto, declara que la nación argentina establece para su gobierno la forma republica y federal. Cabe preguntarse cuál es entonces el real contenido de la frase.

Si bien tradicionalmente los dos vocablos se utilizaron en forma indistinta, la ciencia política entiende que ambos términos denotan cuestiones diferentes. Cuando hablamos de forma de gobierno nos referimos al modo en que un gobierno ejerce el poder sobre la población sometida a su soberanía. En cambio, en los casos que analizamos las formas del estado estamos frente a las posibles maneras en que el poder se distribuye en el espacio físico de un territorio determinado.

Esta concepción que a primera vista aparece como compleja, es más clara si se analiza un ejemplo práctico. Tomemos el

caso de la sanción de una ley respecto a los delitos informáticos. La forma del estado nos dirá cuál es el estado (nacional, provincial o municipal) competente para sancionarla o, puesto de otra forma, si se trata de una competencia de las provincias o del estado central. En cambio, si estamos analizado el problema desde la óptica de la forma de gobierno, nos estaremos preguntando cuál es órgano dentro del estado competente con capacidad para dictar la norma, la forma en que el mismo se conforma, la permanencia de las personas en dicho cargo, etc.

II.- La forma de Gobierno Monarquía y República.

La mayoría de los autores que se han acercado a la teoría política realizaron clasificaciones respecto de las formas de gobierno. Aristóteles en su obra *Política*, plantea la posibilidad de analizar la existencia de formas puras e impuras del gobierno. En este sentido, define que un gobierno en manos de una sola persona en sus formas puras se trataría de una monarquía mientras que una forma degradada de la misma estructura sería una tiranía. Sin, en cambio, el poder se encuentra en manos de unas pocas personas es trataría de una aristocracia, transformándose en una oligarquía en los casos de una forma envilecida. Por último, cuando estamos frente a un ejercicio del poder por parte de toda la población hablaríamos de una democracia o en los casos que la misma se degrade, de demagogia.

El problema básico de la clasificación de Aristóteles consiste en la inclusión dentro de los criterios de valoración un componente axiológico. Dicho de otro modo: El filósofo griego no describe formas de gobierno sino que las valora; un sistema político es una democracia o una demagogia no ya en función de sus propias características internas sino por el juicio de valor, siempre subjetivo, de quien realiza la clasificación.

En tal sentido, hubo que esperar hasta el renacimiento para poder encontrar una clasificación carente de contenido axiológico. Fue el florentino Nicolás Maquiavelo quien en sus obras *“Discurso sobre la primera década de Tito Livio”* y sobre todo *“El Príncipe”* esbozó la ahora separación clásica entre la Monarquía y la República. Y decimos esbozó en un doble sentido: En primer lugar porque las repúblicas del renacimiento

italiano diferían en forma sustancial con lo que hoy conocemos como una república. En segundo lugar, porque el autor no intentó en estos libros realizar un tratado teórico de las formas políticas: Ambas obras se encuentran ancladas en la práctica del poder y no en su deber ser: Maquiavelo no describe un tipo ideal de estructura de gobierno sino que analiza el ejercicio del poder en dos circunstancias diferentes, determinadas por la existencia o no de una figura concentratoria del poder como el príncipe. Atento ello, toda clasificación derivada de la obra del florentino necesariamente carecerá de un encuadre teórico, valiéndose de un básicamente de la generalización de los ejemplos dados en las obras y no en el análisis de las definiciones.

Más allá de ello, podemos decir que existen dos formas básicas de organización del gobierno en la actualidad: La Monarquía y La República. En la primera nos encontraremos frente a un estado encarnado en la figura de una persona determinada (el príncipe, rey o cualquier otro término a utilizar) mientras que en la república el ejercicio del poder se encuentra descorporizado, siendo ejercido por un conjunto de magistraturas en las que las personas que las ocupan resultan indiferentes.

Dentro de la monarquía nos encontramos con dos vertientes básicas, según si el monarca simplemente representa al estado sin ejercer el poder o si el mismo detenta en forma directa la voluntad del estado. En el primero de los casos nos encontraremos frente a una monarquía constitucional, en el segundo, frente a una absoluta. Un ejemplo de monarquía constitucional es la española: La familia Borbon representa al Estado Español y promulga las leyes del ordenamiento (las cuales suelen recibir el nombre de reales decretos), sin embargo el gobierno se encuentra en mano de la sociedad civil quien elige en forma democrática un jefe de gobierno, un parlamento y cuenta con una justicia independiente. El rey, en tales casos, manda pero no gobierna.

Diferente es el caso de una monarquía absoluta. En tales sistemas la voluntad del soberano se confunde con la del estado, permaneciendo el monarca fuera del ordenamiento jurídico que el mismo crea. Tal es el caso de las monarquías europeas del siglo XVIII y en la actualidad de algunos países del oriente medio.

En contraposición la república tal como la conocemos en la actualidad se basa en la idea de un mandato popular ejecutado por personas elegidas como representantes, las que ejercen una magistratura periódica, que existe con prescindencia de quien la detenta. Jurídicamente se caracteriza a través de las siguientes características:

1.- División de Poderes: La función estatal se encuentra dividida entre los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales cumplen una actividad específica y limitan las potestades de los otros dos, logrando de esta forma un equilibrio.

2.- Principio de igualdad: El verdadero alcance de este concepto fue formulado por la Corte Suprema de la Nación en su jurisprudencia sosteniendo que la igualdad debe ser entendida como la inexistencia de diferencias irrazonables entre personas que se encuentran en la misma situación de hecho. De esta forma, el principio se quebranta no cuando existe una diferencia de tratamiento entre dos sujetos sino cuando esta diferencia no se sustenta en un principio razonable sino en el prejuicio u otro fundamento arbitrario.

3.- La elección popular de los gobernantes: Como consecuencia de lo anterior, el fundamento del poder de los gobernantes radica en el mandato que la población (sus iguales) le otorga. Así en el caso Alem de 1893, la Corte Suprema sostuvo que *“En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria”*.

4.- Temporalidad de los cargos de gobierno: es decir es necesaria la renovación periódica de los cargos de gobierno. En realidad esto se da en los poderes legislativos y ejecutivos, ya que los jueces, para salvaguardar su autonomía, mantienen el derecho a la inamovilidad de su cargo mientras dure su buena conducta.

5.- Responsabilidad de los gobernantes: A diferencia de una monarquía absoluta, el gobernante de una república no se encuentra excluido del ordenamiento jurídico que crea, de forma tal que sus actos implican similares consecuencias que las que tendría para una persona particular.

6.- Publicidad de los actos de gobierno: Las leyes y reglamentos emanados del gobierno deben ser conocidos por la población, a la cual esta representa. En la práctica esto se da mediante la publicidad de los debates parlamentarios, así como principalmente mediante la divulgación de las normas en el Boletín Oficial, publicación periódica que recoge las leyes y reglamentos promulgados por el poder ejecutivo.

III.- Formas del estado: Sistemas Unitarios y Federales:

La forma del estado define la manera en que el poder del estado se encuentra distribuido en un territorio determinado. En tal sentido, un estado nacional puede estructurarse como un poder único y central que delega funciones en las administraciones locales una serie de funciones que le competen originariamente. Estaríamos en tal caso ante un estado unitario.

Sin embargo, puede suceder que, por diversos factores, en particular de carácter histórico, el estado nacional se configure en razón de la unión de estados locales ya existentes, los cuales delegan en el poder central una serie menor o mayor de facultades. Tal es el caso de la organización de los cantones suizos o las colonias estadounidenses. En tales casos nos encontramos frente un estado federal.

La consecuencia principal de la forma federal del estado es que las competencias otorgadas al estado nacional tienen un carácter restrictivo. Si las provincias son preexistentes a la nación, toda facultad no delegada le sigue perteneciendo, por lo que las atribuciones del estado central se encuentran circunscritas solamente a lo expresamente autorizado.

Ello no quiere decir que la existencia de un estado federal implique necesariamente una mayor independencia de las administraciones locales. En tal sentido, es la real distribución de potestades entre la nación y las provincias la que define la autonomía política de los gobiernos locales y no la existencia de competencias reservadas. Una simple comparación entre las facultades otorgadas a las comunidades autónomas de

España y las provincias argentinas demostrará que, políticamente, estas últimas se encuentran mucho más limitadas en sus atribuciones a pesar de ser un estado federal.

El caso argentino es particular atento la existencia de un esquema original centralizado (el Virreinato del Río de la Plata), el cual por razones políticas desaparece en la década de 1820, persistiendo solo las provincias que la conformaban como forma organizada de ejercicio del poder. Son estas las que, a partir de 1853, se reúnen en congreso general constituyente y dan forma al estado nacional argentino, el cual termina adoptando la forma federal de estado.

La razón fundamental de la lentitud en la organización institucional fue que el período comprendido entre ambas fechas se caracterizó por la disputa entre los partidarios de un estado unitario con sede en Buenos Aires y los que sostenían la necesidad de un estado federal que contemplara las diferencias locales. La solución arribada fue un compromiso entre ambas posiciones, estableciendo un gobierno federal con amplias atribuciones para el estado central

Es por ello que la distribución de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos locales en el estado argentino presenta diferencias sustanciales con los ejemplos anteriormente mencionados, marcando una tendencia a la centralización de las funciones. Así, las competencias legislativas de fondo que en la mayoría de los países federales se encuentran en cabeza de los gobiernos locales, en la Argentina son prerrogativa del estado federal, reservándose solamente la legislación de forma. Dicho de otro modo, es potestad del gobierno central el dictado de la legislación civil, comercial o penal, mientras que son las provincias las encargadas de determinar la forma en que los derechos consagrados por estas leyes se ejercen en sede judicial. Sobre esta división de competencias volveremos cuando analicemos la actuación judicial del perito informático.